

1501449-78.2019.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA MORAES CORREGIARI BEI

Comarca: Jandira

Foro: Foro de Jandira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEYTON DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MORAES CORREGIARI BEI

Vistos.

CLEYTON DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, da Lei 11.343/2006 porque, segundo a denúncia, em 22 de maio de 2019, por volta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jandira

Foro de Jandira

2ª Vara

Avenida Antonio Bardella, 401, Jandira-SP - cep 06618-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501449-78.2019.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEYTON DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MORAES CORREGIARI BEI

Vistos.

CLEYTON DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, da Lei 11.343/2006 porque, segundo a denúncia, em 22 de maio de 2019, por volta das 17h, na Rua Martin Luther King, 100, em Jandira, trazia

consigo, para fins de distribuição a terceiros, 3 porções de maconha, pesando 2,4g, 39 porções de cocaína, pesando 44,1g e 22 porções de crack, pesando 9,9g, consoante auto de apreensão de fls. 10 e laudo de constatação de fls. 11/14. Narra a peça acusatória que guardas municipais em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, avistaram o réu e outros dois indivíduos em atitude suspeita. Ao notarem a presença dos guardas, os três correram. Durante a fuga, o réu dispensou uma sacola no chão. Cleyton foi alcançado e abordado. Na sacola por ele dispensada, foram encontradas as drogas apreendidas.

Recebida a denúncia (fls. 53), o réu foi citado (fls. 68) e apresentou defesa previa (fls. 72/73).

Na instrução do feito, foram inquiridas duas testemunhas de acusação, uma testemunha de defesa e, ao final, o réu foi interrogado.

Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela aplicação da pena no mínimo legal, a redução da pena nos termos do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06 e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O entendimento jurisprudencial consolidado de que os depoimentos dos agentes policiais são prova suficiente para embasar um decreto condenatório está fundado na presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, de que a atividade policial é espécie.

Conforme doutrina do mestre Hely Lopes Meirelles, a presunção de legitimidade dos atos administrativos decorre do princípio da legalidade da administração, pelo qual todos os atos do poder público devem estar fundados em lei, sendo a presunção de veracidade, a ela inerente, atinente aos fatos alegados pela administração para a prática do ato. Tais presunções justificam-se pela necessidade da atuação pronta e célere do Estado, autorizando a imediata execução dos atos administrativos e resultam na inversão do ônus da prova em desfavor do administrado, a quem caberá demonstrar a ilegalidade do ato (in Direito Administrativo Brasileiro, 34a Edição, pg. 161).

De fato, os atos de polícia, ou seja, os atos praticados pelo Estado para preservação da segurança pública, são atos administrativos e, como tais, gozam dos atributos da presunção de legitimidade, imperatividade e auto-executoriedade. Da mesma forma, devem observar os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, previstos no artigo 37, da Lei Maior e devem conter os elementos essenciais de validade dos atos administrativos, consistentes na competência, forma, motivo, finalidade e objeto, sujeitando-se a controle de legitimidade.

Pois bem, o efetivo controle da legitimidade dos atos administrativos é essencial em um Estado Democrático de Direito, impedindo a prática de atos arbitrários pelo Poder Público. Por controle efetivo entende-se a análise não apenas dos requisitos formais, mas a verificação da existência dos motivos declarados para a prática do ato e da obtenção do resultado de interesse público previsto na lei.

Ora, a decisão pela prática do ato administrativo é feita pelo agente público competente para tanto, cabendo a ele declarar os motivos que ensejaram a medida, a justificativa legal para sua adoção e a finalidade pretendida.

Sendo assim, o agente que praticou o ato irá naturalmente relatar motivos que se coadunem com a lei invocada e com a finalidade declarada, justificando suas

próprias ações. Bem por isso, o agente responsável pelo ato não tem neutralidade para atestar a veracidade dos motivos que fundamentaram sua prática, tornando necessária a obtenção de outros elementos que demonstrem que os motivos realmente existem para que haja efetivo controle de legitimidade do ato.

Imagine-se, por exemplo, um ato administrativo de contratação com dispensa de licitação fundamentado em situação de emergência. Para que tal contratação seja considerada legítima, é preciso verificar se realmente existe uma situação emergencial tal como exigida pelo artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, não bastando a declaração prestada pelo agente público. Por esta razão, a própria lei exige a realização de um processo de dispensa, devidamente instruído com prova da situação emergencial (artigo 26, parágrafo único, inciso I). Com isso, garante-se transparência à atuação do Estado e coíbem-se abusos.

O mesmo raciocínio deve ser aplicado à prisão em flagrante realizada pelo agente policial. A Constituição Federal estabelece que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei (art. 5º, LXI).

Por sua vez, o artigo 302, do Código de Processo Penal, dispõe que "considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Desta forma, ao apresentar um preso em flagrante na Delegacia de Polícia, o agente policial irá necessariamente descrever uma das situações que, segundo a lei, caracterizam flagrante, apresentando versão que legitime sua ação. Do contrário estaria admitindo que agiu fora das hipóteses legais e que cometeu o crime previsto no artigo 90, da Lei 13.869/2019.

Nesse contexto, para que haja controle efetivo da legitimidade da prisão em flagrante, é imprescindível que o próprio Estado exija que os agentes da força policial apresentem elementos de prova que corroborem sua versão, garantindo transparência e coibindo abusos.

Todavia, o que vem ocorrendo é justamente o contrário. Sabendo que sua palavra será considerada como suficiente para a condenação, os agentes que realizam o flagrante ignoram outros meios de prova disponíveis, deixando de arrolar testemunhas e de documentar devidamente suas ações. A polícia judiciária, por seu turno, apenas colhe a versão apresentada pelos agentes que apresentaram o flagrante, deixando de realizar diligências que seriam importantes para elucidação dos fatos.

Neste cenário, fica patente a disparidade de armas entre a acusação e a defesa, sendo muito mais difícil ao acusado comprovar que os fatos não ocorreram como narrado pelos guardas ou policiais do que seria aos agentes da lei apresentar outras provas que corroborassem sua versão.

É preciso considerar que os acusados são apresentados na delegacia sem a presença de um defensor e, no mais das vezes, não têm condições financeiras de contratar um advogado, sendo representados por defensores dativos que apenas tomam conhecimento dos fatos após o recebimento da denúncia, ou seja, muito depois da conclusão do inquérito policial. É evidente que, nestas circunstâncias, o acusado fica impedido de requerer diligências à autoridade policial para demonstrar que os fatos não ocorreram da forma descrita pelos agentes policiais que apresentaram o flagrante e, desta forma, evitar o processo criminal.

Nesse ponto, transcrevo a lição precisa do mestre Dalmo de Abreu Dallari:

"Nas sociedades democráticas modernas, submetidas ao império do direito, a proteção dos direitos humanos no caso de grave ameaça, como também o castigo dos responsáveis por toda ofensa a esses direitos, é tarefa que incumbe ao Poder Judiciário de cada Estado. (...) É preciso ter muito claro, entretanto, que para a real proteção judicial dos direitos humanos não é suficiente e, pelo contrário, é perigoso só cumprir formalidades judiciárias, ter uma aparência de proteção judicial, que adormece a vigilância e que não é, porém, mais do que uma ilusão de justiça." (in O Poder dos Juízes, 3a Edição, pg. 38)

Não basta, portanto, afirmar que os réus tiveram oportunidade de apresentar sua versão à autoridade policial, garantindo seu direito ao contraditório. É preciso considerar a posição vulnerável em que os presos em flagrante se encontram no momento da apresentação na delegacia, especialmente quando se trata de pessoas humildes, sem conhecimento sobre seus direitos e cujas famílias estão submetidas diuturnamente à mesma força policial que os acusa.

É preciso, ainda, ter em mente que os episódios de abuso de poder em ações policiais minam a confiança da população não apenas na polícia, mas em todas as instituições democráticas, fragilizando a legitimidade do próprio Estado e agravando o problema da violência, ao propiciar o surgimento de métodos ilegais de solução de conflitos.

Desta forma, para efetiva garantia do direito constitucional à ampla defesa, deve ser exigido dos agentes da lei que busquem elementos de prova que demonstrem a ocorrência do crime, deixando de contar apenas com a credibilidade dada à sua palavra para tanto.

Atualmente, existe meio eficaz e acessível de documentação da ação policial, consistente na utilização das câmeras de corpo pelos agentes, registrando continuamente a atuação em áudio e vídeo e permitindo que se verifique se a situação ocorrida configura uma das hipóteses de flagrante delito ou não.

O Estado de São Paulo assinou, em 05 de fevereiro de 2021, contrato para compra de 2,5 mil câmeras para utilização por policiais militares, conforme notícia divulgada no site oficial do governo, em que se lê:

"O Governador João Doria anunciou, nesta quarta-feira (10), a aquisição de 2,5 mil novas câmeras corporais para a Polícia Militar de São Paulo. O equipamento é acoplado aos uniformes e grava automaticamente todas as atividades policiais, transmitindo imagens em tempo real para centrais específicas e garantindo acompanhamento instantâneo das ações em diferentes regiões do estado.

"No último dia 5 de fevereiro, foi assinado o contrato para a aquisição de mais 2,5 mil câmeras corporais no programa Olho Vivo. Elas começam a ser distribuídas no mês de março. O uso de câmeras portáteis acopladas aos uniformes fortalece a produção de provas e, ao mesmo tempo, protege os cidadãos e os policiais, dando mais transparência ao trabalho da PM", disse Doria. Ele também ressaltou que a PM de São Paulo é a primeira a utilizar câmeras portáteis em grande escala e com a atual tecnologia em todo o Brasil.

A aquisição das câmeras ocorreu por meio de licitação internacional no final de 2020, com publicação do edital no Diário Oficial do Estado em 17 de outubro. A empresa do consórcio Advanta/Axon foi a vencedora. O contrato de 30 meses tem valor mensal de R\$ 1,2 milhão para operação e gestão completa do sistema. Após a contratação, são 90 dias para a entrega. A expectativa é que a nova tecnologia entre em operação já no primeiro semestre de 2021.

Com capacidade para captar som e imagem, as câmeras corporais contribuem decisivamente para fortalecer a produção de provas judiciais durante ocorrências

criminais. Os registros também garantem os direitos individuais dos cidadãos e preservam a atuação dos policiais, garantindo mais transparência e legitimidade às ações da corporação.

Atualmente, a PM já conta com 585 câmeras portáteis em operação. Essas unidades foram obtidas em parceria com a iniciativa privada e estão em uso desde agosto de 2020 nas regiões central e sul da capital paulista.

As câmeras portáteis são acopladas aos uniformes e gravam automaticamente todas as atividades policiais durante o turno de serviço. Ou seja, todas as abordagens, fiscalizações, buscas, varreduras, acidentes e demais interações com o público são registradas independentemente da ação do policial. Os dados são transmitidos em tempo real por meio de live streaming ou armazenados na nuvem para acesso remoto das autoridades de segurança e judiciais sempre que necessário.

A localização por GPS também facilita a produção de provas e garante mais segurança aos policiais. Com o equipamento acoplado ao corpo, o policial pode ter sua posição facilmente rastreada e informada com exatidão a outras equipes da PM em casos de necessidade de reforço.

(<https://www.saopaulo.sp.gov.br/sala-de-imprensa/release/governo-de-sp-adquire-25-mil-novas-cameras-corporais-para-a-policia-militar-2/>)

Conforme se verifica, a implantação do programa tem por finalidade "fortalecer a produção de provas judiciais durante ocorrências criminais", garantir "os direitos individuais dos cidadãos" e preservar "a atuação dos policiais, garantindo mais transparência e legitimidade às ações da corporação".

Todavia, o programa é ainda incipiente e a quantidade de câmeras adquiridas muito inferior ao número de policiais militares que atuam no Estado. Além disso, não abrange as guardas municipais existentes em muitos Municípios.

Desta forma, enquanto não for adotado o amplo uso da câmera de corpo, os agentes policiais terão que buscar outras provas, como testemunhas da ação, imagens de câmeras de vigilância existentes nas proximidades ou, até mesmo, gravar a ação com seu próprio celular.

Para que tal postura seja adotada como padrão, é imprescindível que o Poder Judiciário reconheça que a presunção de legitimidade da atuação policial serve apenas como pressuposto para a auto-executoriedade e imperatividade inerentes à atuação do Estado. No entanto, não pode afetar a valoração da prova na esfera criminal, que deve ser feita levando em conta o interesse do agente policial em apresentar versão que legitime sua ação.

Estabelecidas tais premissas, verifica-se que, no caso presente, embora tenha havido apreensão das drogas (fls. 10), a única prova produzida em relação à autoria foi a oitiva dos agentes públicos que realizaram a prisão em flagrante.

O guarda municipal Márcio Alves de Oliveira afirmou que estava em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando avistou três indivíduos em atitude suspeita. Ao verem a viatura, os três saíram andando. Viu quando o réu dispensou uma sacola no trajeto. O réu foi abordado a cerca de cem metros do local em que dispensou a sacola. Os outros indivíduos conseguiram fugir. Ao perceber que a sacola havia sido localizada, o réu tentou correr e entrou em luta corporal com o guarda Adriano.

O guarda municipal Adriano Villela narrou que estava em patrulhamento pelo local dos fatos quando avistaram três indivíduos que correram ao verem a viatura. Um deles jogou uma sacola. Este indivíduo foi detido. Ficou com ele enquanto seu parceiro foi pegar a sacola e ele ficou agitado, o empurrou e saiu correndo. Foi atrás dele. Ele se jogou no córrego para se esconder, mas foi encontrado. Os outros indivíduos que correram foram detidos por outra equipe, mas foram liberados. Não viu eles sendo detidos.

Raquel, ouvida como informante, afirmou que é vizinha do réu e sabe que ele é usuário de maconha e cocaína. No dia dos fatos, percebeu uma confusão na rua. Quando chegou na rua Martin Luther King, viu o réu algemado.

O réu negou a prática do crime. Disse que estava indo comprar maconha e não tinha nenhuma sacola em seu poder. Os guardas acharam a sacola há mais de quinhentos metros. Foi abordado na rua de cima, em Itapevi e não na Rua Martin Luther King. Havia muitos guardas e eles ficaram andando na rua. Um deles se aproximou e disse "a casa caiu". Foi agredido pelos guardas quando foi abordado porque eles queriam que falasse para onde os outros tinham corrido. Correu quando viu os guardas porque sabe que acontece de policiais e guardas forjarem contra quem tem passagem anterior.

Diante da negativa de autoria e não havendo outras provas que corroborem a versão dos agentes que fizeram a prisão em flagrante, há que se reconhecer a insuficiência de provas para a condenação.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para ABSOLVER o réu da imputação que lhe foi feita na denúncia, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Por consequência, revogo as medidas cautelares fixadas na decisão de fls. 34/36.

Expeça-se certidão de honorários ao patrono nomeado para a defesa, nos termos do Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB/SP.

Publique-se, intímese e comuniquem-se.

Jandira, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA